

1501081-37.2020.8.26.0024

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael

Comarca: Andradina

Foro: Foro de Andradina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... por duas vezes, sendo uma delas por tráfico (processos 0005797-60.2015.8.26.0024 e 0004702-58.2016.8.26.0024, relativos à execução das medidas e 0000003-58.2015.8.26.0024 de apuração do tráfico). Além disso, foi condenado definitivamente por porte de arma (fl. 269) e não definitivamente por tráfico (processo 1500204-03.2020.8.26.0605), em processo em que a corré ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Andradina

Foro de Andradina

3ª Vara

Rua Paes Leme, 2052, Andradina-SP - cep 16901-110

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501081-37.2020.8.26.0024 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501081-37.2020.8.26.0024

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 12130269 - DEL.SEC.ANDRADINA, 690/2020 - DEL.SEC.ANDRADINA, 2151091-36.2020 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Andradina

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

RAFAEL CANDIDO PEROZINI

O Ministério Público ofereceu denúncia contra RAFAEL CANDIDO PEROZINI imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).

Narra a denúncia que no dia 28 de junho de 2020, às 16h10min, na Rua Isabel Santos Knetch, nº 235, esquina com a Avenida Guanabara, Stella Maris, nesta cidade e comarca de Andradina, o réu, qualificado a fls.10, 13, 16/17 e 18/22 dos presentes autos, atuando em concurso e com unidade de desígnios com o inimputável Felipe Cândido Perozini, seu irmão, adquiriu em outra unidade da federação, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, para entrega a consumo de terceiros, 01 porção de cocaína em pó, num total de 5,6g, e duas porções de cocaína em pedra ("crack"), totalizando 35,76g (cf. auto de constatação provisório de fls.63/66), substância esta entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021, em fls.251/252. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação em fls.242/250.

Após regular instrução, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, entendendo demonstradas a materialidade e autoria do delito imputado; a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, afastamento das causas de aumento e aplicação do redutor do parágrafo

quarto.

É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO.

Inexistem nulidades ou irregularidades a serem sanadas. O feito tramitou regularmente. Não foram arguidas preliminares ou questões prejudiciais aptas a impedir o prosseguimento da marcha processual, razão pela qual passo à análise do mérito da lide.

Desde logo anoto ser inviável o pedido da defesa para instauração de incidente de dependência toxicológica, seja porque inexistem indícios suficientes de que o réu tenha praticado o fato sem capacidade de autodeterminação por conta de dependência, seja porque o pedido foi feito em memoriais, após encerramento da instrução (CPP 402).

Após detida análise das provas produzidas e sopesadas as alegações das partes, conclui-se pela parcial procedência da acusação.

Com efeito, a ocorrência do delito foi demonstrada pelos elementos da investigação (APF de fls 01/04 e boletim de ocorrência de fls.48/53 ,termo de depoimento de fls.05/08;termo de declarações de fl.09, autos de exibição e apreensão de fls.54/55,fotografias de fls.56/60; laudos IC - objeto de fls.179/185), bem como pelo resultado da instrução em juízo.

A autoria também foi comprovada, pelos elementos já indicados, prisão em flagrante e pelos consistentes relatos das testemunhas.

A prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, foi no seguinte sentido:

Os policiais militares Paulo Adriano Crepaldi e Cristiano Fernandes Coutinho disseram em uníssono que receberam informações por diversas vezes indicando Rafael como traficante e decidiram passar em sua casa para abordá-lo. Encontraram-no na frente do imóvel e com a chegada da polícia ele tentou voltar para seu interior. Abordaram-no e com ele havia uma porção de cocaína. No interior da residência encontraram mais duas pedras médias de crack e uma balança de precisão.

Desconheciam o envolvimento do irmão do acusado, sendo que na hora da sua prisão este falava para Felipe assumir a droga, até em tom de intimidação.

Interrogado, o réu negou a traficância. Disse que à época era usuário de cocaína. Estava na parte externa da casa para ir ao banheiro quando a polícia chegou e o prendeu. Estava apenas com a cocaína que seria para seu uso. Desconhecia a presença de crack no local. Morava ali com sua esposa e sua filha. Seu irmão não morava na casa, mas ia sempre lá.

Com efeito, o art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 diz que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Na hipótese houve firme relato dos policiais no sentido de que apreenderam relevante quantidade de cocaína e crack na residência do réu. Apenas a título de argumentação, anote-se que uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente e a pedra de crack para imediato consumo tem em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr nº 0000152-73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5ª Câmara Criminal, j. 26/10/2017). Ou seja, a quantidade localizada em poder do acusado seria suficiente para até 50 doses de cocaína e mais de 150 cachimbos de crack. Ainda, note-se que houve apreensão de uma balança de precisão, sendo que o local era a própria residência do réu, e não de seu irmão.

O histórico do réu também não o favorece. Anoto que já cumpriu medida socioeducativa por duas vezes, sendo uma delas por tráfico (processos 0005797-60.2015.8.26.0024 e 0004702-58.2016.8.26.0024, relativos à execução das medidas e 0000003-58.2015.8.26.0024 de apuração do tráfico). Além disso, foi condenado definitivamente por porte de arma (fl. 269) e não definitivamente por tráfico (processo 1500204-03.2020.8.26.0605), em processo em que a corré também afirmou que o réu era traficante à época (o fato é de 04/07/2020, ou seja, uma semana antes do fato narrado nestes autos).

Anoto, ainda, que o acusado não soube explicar o encontro de tamanha quantidade de crack na casa, e se diz usuário apenas de cocaína.

Não é crível que seu irmão de apenas 13 anos guardasse tamanha quantidade de droga,

além de balança de precisão, à sua revelia no local.

Por sua vez, o tráfico de drogas é crime de ação múltipla (tipo misto alternativo/conteúdo variável) e a prática de quaisquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente (HC 332396/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria 5ª Turma, julgado em 23/02/2016, e AgRg no AREsp 397759/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, Julgado em 04/08/2015).

Outra questão a ser ponderada é que as posições de usuário de drogas e traficante não são excludentes entre si. Em outras palavras, mesmo que o réu seja efetivamente usuário de drogas isso não é impeditivo para o reconhecimento do delito de tráfico – o usuário pode muito bem também ser vendedor ou, ainda, o vendedor ser usuário. Corroborando tal raciocínio: “a alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (RJTJ 101/498).

Aliás, é comum que usuários adentrem ao mundo do tráfico justamente para sustentar o vício, por ser a atividade ilícita extremamente lucrativa.

Diante desse contexto probatório, não há dúvidas de que a imputação do delito de tráfico de drogas é procedente.

Entretanto, entendo que devam ser afastadas as causas de aumento. Ainda que o adolescente tenha confirmado em outra sede a compra da droga em outro Estado e confessado seu envolvimento, certo que as provas destes autos indicam em sentido diverso. Não há provas efetivas do envolvimento de Felipe, ou mesmo do local de aquisição do entorpecente. Sendo independentes as instâncias, este juízo deve ater-se ao conjunto probatório realizado nestes autos, não se vinculando ao ato decisório anterior, até porque não se descarta a hipótese de que Felipe tenha assumido a propriedade da droga na esperança de ver seu irmão livre da acusação. E o testemunho dos policiais não deve ser desacreditado apenas pela sua condição funcional. Não demonstraram ser tendenciosos ou qualquer especial disposição para prejudicar o réu, devendo o seu testemunho ser valorado como qualquer outro. Esta é a jurisprudência já pacífica sobre a condição de testemunha dos policiais militares e outros agentes de segurança.

Impondo-se a condenação, resta a fixação da sanção correspondente.

Critérios para fixação da pena:

Antes de iniciar a fixação da pena propriamente dita, cabem alguns esclarecimentos sobre os critérios gerais a serem utilizados para a dosimetria, especialmente sobre a forma de cálculo das frações de aumento e diminuição. A base de cálculo será o intervalo entre a pena mínima e máxima do delito, e não a pena mínima.

Na primeira fase, na qual fixa-se a pena-base, existem oito circunstâncias judiciais passíveis de valoração. A pena sempre partirá do mínimo previsto e, a cada circunstância judicial desfavorável ao acusado, somar-se-á à reprimenda mínima cominada a fração de um oitavo (pois são oito circunstâncias), calculada pelo intervalo entre o máximo e o mínimo de pena previstos em lei para o crime em questão. A partir deste intervalo entre a pena máxima e a mínima encontra-se a fração respectiva de um oitavo para cada circunstância desfavorável.

Exemplificando-se, para melhor compreensão: se um crime tem pena mínima de 12 anos e máxima de 20 (como ocorre com o tipo previsto no art. 159, § 1º do Código Penal), o cálculo das frações é feito sobre o intervalo de 8 anos entre a pena mínima e máxima, e não sobre os 12 anos da pena mínima. A cada circunstância negativa considerada somar-se-á à pena mínima 1/8 sobre oito anos, o que representa um ano. Se não houver circunstância negativa, a pena-base será a mínima, de 12 anos; ao contrário, se todas forem desfavoráveis, a pena parte do máximo legal, 20 anos. Tal forma possibilita ao mesmo tempo: i) controle sobre os patamares utilizados pelo julgador, que se move em espaço conferido pelo legislador por meio de critério racional; ii) proporcionalidade, pois cada circunstância terá, em regra, peso semelhante e será calculada de acordo com os patamares mínimo e máximo da pena, abarcando de forma global a gravidade do crime; iii) fixação da pena partindo sempre do mínimo legal, com a possibilidade de se chegar ao máximo previsto, caso as oito circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis.

O critério também evita indesejáveis discrepâncias, como nos casos de crimes com

pena mínima muito elevada ou diminuída. Se o cálculo partir da pena mínima, pode-se chegar a exasperações exageradas (como no caso da extorsão mediante sequestro seguida de morte, cuja pena mínima é de 24 anos) ou ínfimas (neste caso nunca se chegando perto da pena máxima cominada para o delito, como no crime de ameaça). Ademais, permite que crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta (como a lesão corporal do caput e a figura do § 9º), sejam apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei. Seria injusto que para crimes de diferente gravidade a exasperação da pena-base partisse do mesmo patamar.

Via de regra, este será o critério utilizado na primeira fase. Diante da peculiaridade de cada caso as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas, para que se possa individualizar adequadamente a pena, de forma fundamentada (como por exemplo, nos casos de várias condenações criminais ou reincidência específica). O critério explicitado servirá sempre de parâmetro, porém não impedirá seja a pena-base fixada de modo diverso (para mais ou menos) se o caso assim recomendar (valendo isto também para a segunda fase).

Na segunda fase, na qual incidem agravantes e atenuantes, a fração usada para valoração será, no mais das vezes, de um sexto (1/6), calculado ou sobre o intervalo entre pena mínima e máxima, como acima, ou sobre a pena-base já fixada - o que for maior.

E utilizar-se-á o maior valor por uma razão simples: há uma hierarquia no sistema trifásico que deve ser respeitada. O sistema trifásico é escalonado, tendo cada fase maior relevância sobre a precedente. As circunstâncias do art. 59, valoradas pelo julgador, jamais podem preponderar sobre agravantes ou atenuantes, elevando a pena em patamar acima destas, que já foram estipuladas como mais graves de antemão pelo próprio legislador. A fração de 1/6 será utilizada pois é a menor prevista para as causas de diminuição e de aumento de pena e, com isso, respeita-se novamente a hierarquia do sistema trifásico.

Por fim, como não poderia deixar de ser, as causas de aumento ou de diminuição de pena incidirão sobre a reprimenda fixada provisoriamente na primeira e segunda fases, de forma sucessiva (incidindo umas sobre as outras, em cascata), segundo entendimento preponderante nos tribunais. Do contrário poderia se chegar ou a penas negativas, no caso de diversas causas de diminuição, ou na utilização de critérios distintos para causas de aumento e de diminuição, o que não é isonômico.

Friso que o critério ora explicitado vem sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (HC 498586 / SP - 5ª Turma - julgado em 11/02/2020), verbis:

"2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3. As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima. Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais". E ainda (AgRg no REsp 1704633 / TO - 6ª Turma - julgado em 24/09/2019): "A divisão do intervalo entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato pelas oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP é um, entre outros, dos critérios que podem ser utilizados na fixação da pena-base".

Dito isso, passo efetivamente a fixar a pena.

Na primeira fase, a natureza (crack, a droga que mais causa danos à saúde no país) da droga recomenda a exasperação da pena-base em 1/8, pelo critério de cálculo acima explicitado (encontro da fração a partir do intervalo entre a pena mínima e máxima do delito). Nesse passo, estabeleço a pena-base em 6 anos e 3 meses de

reclusão e 625 dias-multa.

Além disso, verifico que o réu ostenta antecedente criminal (fl. 269 - crime de porte ilegal de arma de fogo cometido em 15/04/2020), já que cometeu crime anterior ao fato deste processo, cujo trânsito se deu durante o trâmite deste feito. Veja-se, o entendimento do STJ sobre a matéria (HC 171212 / DF - 6ª Turma - DJe 20/08/2015): "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes."

Assim, exaspero a pena-base em mais 1/8, pelo mesmo critério de cálculo.

A pena fica então em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

A pena-base fica assim inalterada.

Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 por conta dos antecedentes criminais do acusado. Além disso, o histórico infracional citado acima, inclusive por tráfico, impede o benefício (STJ. 3ª Turma. EREsp 1.916.596-SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. Laurita Vaz, julgado em 08/09/2021).

Sendo assim, a pena fica em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa.

O regime inicial, tendo em vista a gravidade do crime, quantidade de pena e antecedentes deve ser o fechado. Pelas mesmas razões, inviável a substituição da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO RAFAEL CANDIDO PEROZINI, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, calculados em seu mínimo legal.

Permito recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas do processo em 100 UFESPs, com as ressalvas da gratuidade.

Com o trânsito em julgado: i) comunique-se ao IIRGD e ii) Justiça Eleitoral, iii) anote-se a condenação (art. 372 das NSCGJ) e iv) expeça-se guia de recolhimento. Caso tal providência já não tenha sido determinada, determino a destruição das drogas apreendidas.

Com relação aos bens apreendidos, tratando-se de objetos utilizados para a prática do crime de tráfico, determino seu perdimento à União (revertendo-se ao Funad), na forma do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, além do Recurso Extraordinário 638.491.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

Andradina, 16 de fevereiro de 2022.

Pedro Luiz Fernandes Nery Rafael
Juiz de Direito
(assinatura eletrônica)